

1511771-95.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS.

DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. ILEGALIDADE VERIFICADA.

1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. A negativa da minorante do tráfico privilegiado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1511771-95.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511771-95.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUANA CRISTINA DOS SANTOS

Juiza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

LUANA CRISTINA DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada e processada como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque, no dia 31 de maio de 2020, por volta das 11h, na Praça da Sé, nessa cidade e Comarca de São Paulo (SP), teria sido flagrada com 3,4 gramas de crack, que trazia consigo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para consumo alheio.

Segundo consta na denúncia, à espreita, policiais militares teriam presenciado a acusada atendendo pessoas, como se estivesse traficando. Em seguida a abordaram. Constataram, então, que ela teria carregado consigo, presos ao sutiã, 17 pedras de crack, acondicionadas em papelotes, e também R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em dinheiro trocado. Interpelada, ela teria confessado que estava traficando.

A natureza e a quantidade da droga, o seu fracionamento e acondicionamento em invólucros, e bem assim a circunstância da acusada ter sido flagrada a postos num ponto de venda de drogas, com dinheiro trocado, evidenciavam a traficância.

A ré foi presa em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 67/71).

A denúncia foi oferecida às fls. 112/114. A decisão de fls. 115 concedeu liberdade provisória à ré, determinando-se a citação e notificação da ré.

Fora designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento no dia 21 de setembro de 2020, às 15h30, todavia, devido à pandemia de COVID-19, a audiência foi retirada de pauta (fls. 143).

A ré foi regularmente citada (fls. 164) e apresentou defesa prévia por meio da Defensoria Pública (fls. 136/138 e fls, 167).

A decisão de fls. 169/170 atestou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 14 de março de 2022, às 14h45.

Durante a instrução, tomou-se o depoimento do policial Alberto Vieira Lima.

Audiência foi redesignada para oitiva da testemunha Denise Clain, bem como, para o interrogatório da Acusada.

Na nova data marcada, colheu-se o depoimento da testemunha faltante, interrogando-se a ré ao final.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação da acusada, nos exatos termos da denúncia vez que comprovados indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.

Já, a Defesa requereu absolvição da ré por falta de provas concludentes para sua condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ressaltando divergências entre os depoimentos apresentados pelos policiais militares. De forma alternativa, em caso de condenação, requereu a desclassificação para uso de entorpecente (artigo 28, da Lei nº 11.343/2.006)e, por fim, caso mantida a condenação, aplicação do redutor legal, fixação de pena no mínimo legal, substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de "sursis", além do direito da ré recorrer em liberdade.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal da acusada pelo delito descrito na denúncia.

Ausentes questões preliminares, presentes as condições da ação e os pressupostos, passo desde logo ao mérito.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02), auto de prisão em flagrante (fls. 03/05), auto de exibição/apreensão (fls. 13), laudo de constatação (fls. 31/33), laudo pericial definitivo (fls. 171/173), além da prova oral colhida em Juízo.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que a acusada está envolvida nos fatos descritos na denúncia, a despeito de suas negativas durante interrogatório judicial.

Vejamos.

A ré, na fase policial (fls. 17), ao ser questionada, alegou que: estava pela Praça da Sé quando foi detida por Policiais Militares que encontraram em seu poder cinco pedras de crack e dinheiro referente a seu auxílio bolsa família. Ao ser questionada que tratava-se de 17 pedras de crack encontradas em seu poder e que o dinheiro que possuía eram em notas de pequeno valor, própria de comercialização de droga, a acusada demonstrou espanto e nada mais disse. Disse que não tem advogado a indicar e não tem familiar para avisar, uma vez que está em situação de rua. Não foi agredida e nem ameaçada.

Ouvida em Juízo, a ré afirmou ser solteira, ter um filho pequeno, ter estudado até a 6ª Série do Ensino Fundamental, estar desempregada. Quanto aos fatos narrados na denúncia, confirma que foi abordada naquela ocasião, na Praça da Sé, juntamente com outros moradores de rua. Admitiu ser viciada no uso de entorpecentes, que à época estava passando grandes dificuldades, com tuberculose, além de ser soro positivo, mas, hoje recebe ajuda de familiares e, não se encontra mais em situação de rua. Disse que foram encontradas cinco pedras de "crack" no interior de um pequeno saco, além de certa quantia em dinheiro junto a uma bolsinha que também era de sua propriedade. Disse que eram cinco pedras de "crack" e, não dezessete, como alegaram os policiais. Acredita que as pedras tenham se quebrado antes da abordagem policial. Quanto ao dinheiro, disse que era seu e o recebeu do Governo Federal, em razão do auxílio emergencial.

A negativa apresentada pela acusada, carente em si de verossimilhança, vem isolada nos autos, confrontada pelo mais da prova colhida, a qual demonstra à saciedade a

realidade da hipótese acusatória.

A testemunha DENISE CLEIM, policial militar em fase policial (fls. 07), relatou que, na data dos fatos: conduziu presa a acusada Luana Cristina dos Santos, para a qual dera voz de prisão pela prática do delito de tráfico de entorpecente. A depoente e seu companheiro de farda encontravam-se em patrulhamento de rotina pela Praça da Sé e observaram movimentação suspeita em área conhecida pela comercialização de entorpecente. Verificaram que uma das pessoas aparentava estar comercializando entorpecente, fato que ensejou abordagem e foi constatado o porte de 17 pedras de crack que a acusada identificada por Luana Cristina dos Santos escondia debaixo do sutiã na bolsa que trazia em sua mão havia a quantia de R\$230,00 em dinheiro trocado e amassado, próprio de comercialização de entorpecente. Foi dada voz de prisão para a acusada que disse estar comercializando a droga pelo local e que fazia desde 13 anos de idade e que já havia sido presa anteriormente por comercialização de entorpecente.

A testemunha ALBERTO VIEIRA LIMA, também policial militar, em fase policial (fls. 08), apresentou idêntico relato ao de sua colega de farda.

O policial ALBERTO ouvido durante audiência, confirmou que no dia dos fatos realizava patrulhamento regular pela Praça da Sé, quando avistou uma movimentação estranha em conhecido ponto de tráfico de entorpecentes (seria uma mini Cracolândia). Realizada abordagem, encontrou as dezessete pedras de crack no sutiã da acusada, assim como a quantia de R\$217,00 (duzentos e dezessete reais). Segundo mencionou, a ré estava em pé, com pessoas ao redor dela, na própria Praça de Sé, próximo ao prédio da Caixa Econômica Federal. Ressaltou, ainda que, inclusive, no dia 15 de maio de 2020, a ré já tinha sido presa, cometendo o mesmo crime. Já, a policial militar DENISE afirmou em seu depoimento que estava participando de operação junto à Praça da Sé e, tinham ordens de abordar todos moradores de rua daquela região (abordaram mais de dez pessoas). Salientou que, a ré aparentava ser moradora de rua, haja vista que, tinha até uma pequena cabana junto ao local dos fatos. Em poder da ré, encontraram dinheiro (não se recorda a quantia exata), algumas porções de cocaína e, entre quinze a dezesseis pedras de "crack", no interior de uma pequena bolsa. Reconheceu a ré em audiência e, por fim, salientou, mais uma vez, que inúmeros moradores de rua foram abordados no local, não somente acusada.

Portanto, como se vê, as circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então a acusada, apresentaram relatos detalhados e convincentes acerca do ocorrido.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convindo notar que a ré não era conhecida anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para se duvidar do depoimento dos policiais, funcionários públicos, haja vista que não há qualquer indício que possa indicar que tivessem interesse em alterar a verdade dos fatos, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar a ré, assomando que imbuídos somente de interesse no esclarecimento da verdade.

É fato que os depoimentos apresentados pelos policiais militares apresentam algumas divergências entre si e, entre os depoimentos apresentados durante a fase policial. Ora, tal situação é perfeitamente compreensível, ante o lapso temporal decorrido, bem como, diante do grande número de ocorrências similares, da mesma natureza. Mas, quanto aos aspectos principais envolvendo a diligência policial, verifica-se que os fatos convergem para o mesmo fim. Ou seja, a ré foi abordada, estava juntamente com outros moradores de rua, apresentava quantia em dinheiro em notas trocadas e miúdas (indicativo de tráfico de entorpecentes), bem como, tinha em seu poder quantia expressiva de "crack", totalizando dezessete pedras.

Frise-se que a versão apresentada pela acusada paira, de forma isolada, no conjunto probatório dos autos, sendo certo, ainda que, o fato da ré ser usuária de entorpecentes, por si só, não exclui atividade de traficância.

O conjunto probatório é seguro e convincente, apesar da negativa da acusada durante seu interrogatório judicial, pela quantidade da droga apreendida, consistente em um montante de 3,4 gramas, no qual foi detectada a presença da substância COCAÍNA, em forma de "crack", a qual se encontra descrita na Lista F1 (Lista das Substâncias Entorpecentes) da Lista F (Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017), bem como pela quantia em dinheiro, no total de R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em cédulas de pequeno valor, corroborado pela narrativa dos policiais que participaram da prisão da acusada, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Destaque-se, por oportuno, que a quantidade da droga apreendida não se presta ao reconhecimento do porte para uso próprio, visto que não se trata, em hipótese alguma, consoante ressaltado, de quantidade irrisória.

A quantidade e o modo de disposição das drogas (embaladas individualizadas) e as circunstâncias em que apreendidas, em ponto conhecido como sendo de tráfico de drogas, mostram-se compatíveis com destinação para o comércio ilícito, de que claramente proveniente o dinheiro apreendido.

Isto em conjunto com as demais provas amealhadas em regular instrução em juízo, denotam a incidência da conduta tipificada no artigo 33, caput da Lei 11.343/06. Quanto à tese defensiva de que o réu faria jus à causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, a despeito de a ré possuir uma condenação anterior pelo artigo 28 da Lei 11.343/06, esta não será considerada para configurar Maus Antecedentes ou qualquer situação impositiva à causa de pena.

Nesse sentido:

CONDENAÇÃO POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO - IMPOSSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES "1 - Em relação à conduta de porte de drogas para consumo próprio, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento de que: "se contravenções penais, puníveis com prisão simples, não têm o condão de gerar reincidência (art. 63 do Código Penal), também o crime de posse de drogas para consumo próprio, punível com medidas muito mais brandas, não deve gerar tal efeito. Nesse passo, se a condenação não se presta para configurar reincidência, também não pode, pelo mesmo raciocínio, configurar antecedente criminal desfavorável." (AgRg no HC n. 520.646/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 21/10/2019).

Destaco, ainda, que as demais condenações (fls. 203/205) são por fatos posteriores ao crime discutido nestes autos, razão pela qual não devem ser consideradas para fins de afastamento da causa de diminuição de pena. Neste sentido há entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS.

DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. ILEGALIDADE VERIFICADA.

1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 3. "A condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada [...], seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal" (HC 534.671/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019). 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover o recurso especial para estabelecer a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, a ser substituída por penas restritivas de direitos, a cargo do Juízo da Execução. (STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1899869 / SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 23.11.2021) - grifei.

Desta forma, a fração de diminuição da pena incide em seu grau máximo, de 2/3 (dois terços).

O conjunto probatório é seguro e convincente, a despeito das negativas da ré, corroborada pela narrativa coesa policiais que participaram de sua prisão, tudo

devidamente ratificado em Juízo.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia.

Passo à dosagem das penas que serão impostas à acusada, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Ao delito descrito pelo artigo 33, caput da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, devem ser consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal e, conforme o artigo 42 da Lei 11.343/06, devem ser consideradas com preponderância a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente. No caso, verifica-se que nenhuma das circunstâncias elencadas têm o condão de agravar a pena base da ré, razão pela qual, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em observância ao princípio da legalidade (Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça).

Desta forma, fica mantida a pena no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, tem-se que a causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º, do artigo 33, incide em grau máximo, de dois terços, como já salientado na fundamentação. Vão as penas, pois, a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

O regime inicial de cumprimento de pena será ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c" do Código Penal.

Não se aplica o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, já que fixado regime mais favorável.

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da pena corporal. Apesar de suspensão vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pela Resolução número 5/2.012 do Senado Federal, a natureza do delito não se coaduna com a benesse pretendida, cuja aplicação redundaria em comprometimento da finalidade da sanção penal, em especial no tocante à função de prevenção geral, não se afigurando a medida socialmente recomendável (artigo 44, inciso III, e § 3º, CP).

A suspensão condicional da pena, contudo, passível de revogação com obrigação de integral cumprimento da pena corporal é admissível, acenando com mais relevante consequência, melhor atendendo ao reclamo de proporcionalidade da pena.

Determino, pois, a suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo período de dois anos, ao longo do qual obrigada a condenada a comparecer mensalmente perante o Juízo de Execução para informar e justificar suas atividades, ficando proibida de mudar de endereço e de se ausentar da comarca de residência sem prévia autorização judicial; no primeiro ano do período de prova, a ré está obrigada a prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas, tal como dispuser o Juízo de execução.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas da acusada, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar a ré LUANA CRISTINA DOS SANTOS, por infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Suspendo a execução da pena de reclusão pelo prazo de 2 (dois) anos, ao longo do qual obrigada a ré a comparecer mensalmente perante o Juízo de execução para informar e justificar suas atividades e proibido de mudar de endereço e de se

ausentar da Comarca de residência sem prévia autorização judicial; no primeiro ano do período de prova, a ré está obrigada a prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas, tal como dispuser o Juízo de execução.

Ausentes causas para a prisão processual, considerando-se o regime imposto, tendo a ré respondido solta, faculto-lhe o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se a ré para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) proceda-se à transferência do dinheiro apreendido a fls. 13 e depositado a fls. 81 ao Funad, decretado seu perdimento em favor da União; d) oficie-se para destruição das amostras guardadas para contraprova (artigo 72, da Lei 11.343/06); e) oficie-se ao TRE para fins do disposto no artigo 15, III da CF/88, f) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil.

Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 1º de agosto de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA